

<제5장 취소소송의 심리.제3절 처분사유의 추가·변경>

I. 처분사유의 추가·변경의 의의

1. 개념

- 처분사유의 추가·변경이라 함은 취소소송의 피고인 행정청이 소송 계속 중 당초 처분 당시에 제시한 처분 사유 이외의 다른 사실 또는 법률적 근거를 추가하거나 변경하여 당해 처분의 적법성을 정당화하려는 소송상 행위를 말한다. 이는 행정절차법상 이유제시 흠결 등으로 인해 실체적으로는 적법한 처분이 단순히 절차적 흠으로 인해 취소되는 것을 방지하고, 소송 경제에 이바지하여 실질적 정의를 구현하기 위한 제도적 논의의 대상이다. 행정처분의 위법성 판단 기준시가 처분사라는 원칙을 전제로 논의된다.

2. 타 제도와의 구별

- 처분사유의 추가·변경은 행정청이 소송 계속 중에 새로운 처분 절차를 거쳐 당초 처분 자체를 소급적 또는 장래적으로 취소하거나 철회 또는 변경하는 처분의 취소·철회·변경과는 구별된다. 후자는 별개의 행정처분이므로 원고는 소를 변경하여 다투어야 한다. 또한, 직권심리주의와도 구별된다. 직권심리주의는 법원이 원고가 주장하지 않은 위법 사유를 직권으로 조사하여 처분의 위법성을 판단하는 법원의 권능이지만, 처분사유의 추가·변경은 피고 행정청이 당초 처분의 적법성을 옹호하기 위해 행하는 소송상 방어 주장이다.

II. 처분사유의 추가·변경의 인정 여부

1. 문제점

- 처분사유의 추가·변경 인정 여부는 행정처분의 적법성 심사의 범위와 관련하여 가장 첨예하게 대립하는 쟁점이다. 국민의 방어권 보장이라는 측면에서 보면, 처분 당시 제시되지 않은 사유를 소송 중에 제시하는 것은 국민의 예측 가능성을 침해하고 이유제시 제도의 취지를 몰각시킨다는 문제가 있다. 반면, 소송 경제 및 실체적 진실 발견이라는 측면에서는 실체적으로는 적법한 처분이 단순한 절차적 하자(이유제시 미비)로 취소되는 것은 행정 효율성 측면에서 바람직하지 않다는 주장이 제기된다.

2. 학설

(1) 부정설

- 처분사유의 추가·변경은 행정절차법상 이유제시 제도의 취지를 정면으로 위배하고 원고의 방어권을 심대하게 침해하므로 절대적으로 허용될 수 없다는 견해이다.

(2) 긍정설

- 소송 경제 및 처분의 실체적 적법성 유지를 위해 일정한 제한 없이 추가·변경을 허용해야 한다는 견해이다. 원고의 방어권 침해 문제는 변론 기회 부여 등 소송 절차를 통해 해결할 수 있다고 본다.

(3) 제한적 긍정설

- 원고의 방어권을 실질적으로 침해하지 않는 범위 내에서 일정한 요건 하에 추가·변경을 허용해야 한다는 견해이다. 이는 현재 통설 및 판례의 입장으로, 기본적 사실관계의 동일성 유무를 제한 요건으로 제시한다.

3. 판례

- 판례는 제한적 긍정설의 입장을 취하면서, 처분사유의 추가·변경이 허용되기 위해서는 당초의 처분사유와 기본적 사실관계의 동일성이 인정되어야 한다고 본다. 이러한 판례의 입장은 당초 처분시부터 존재했던 사실에 대한 법률적 평가나 적용 법조만 달리하는 경우에 한하여 추가·변경을 허용함으로써, 행정청의 방어권을 보장함과 동시에 원고의 방어권을 실질적으로 해치지 않도록 조화를 꾀한다. 판례는 기본적 사실관계의 동일성 여부는 단순히 법률적 관점이 아닌, 구체적 사실관계의 사회적·역사적 동일성 여부에 따라 판단되어야 한다고 본다.

4. 검토

- 처분사유의 추가·변경은 제한적 긍정설에 따라 허용되는 것이 타당하다. 부정설은 절차법적 측면만을 과도하게 강조하여 실체적으로 정당한 처분을 취소하게 하는 불합리를 초래하고, 긍정설은 원고의 방어권 침해 가능성이 높다. 따라서, 판례가 제시하는 기본적 사실관계의 동일성 요건을 통해 그 범위를 엄격하게 제한함으로써, 행정처분의 적법성 유지 필요성과 국민의 방어권 보장 사이의 균형을 이루어야 한다.

III. 처분사유의 추가·변경의 인정 범위

1. 객관적 범위

- 처분사유의 추가·변경이 허용되는 객관적 범위는 당초 처분사유와 추가 사유가 기본적 사실관계의 동일성을 갖는 경우에 한정된다. 기본적 사실관계의 동일성이 인정되기 위해서는, 추가되는 사유가 당초 처분 사유를 구성하는 개별적인 사실 중 일부 또는 당초 사유와 밀접하게 관련된 주변 사실에 해당하여 원고가 이미 알고 있었거나 알았다고 인정되는 경우여야 한다. 새로운 별개의 사실을 추가하여 처분 사유로 삼는 것은 허용되지 않는다. 이는 법률적 평가를 달리하는 것에 불과한지, 아니면 전혀 다른 새로운 사실 관계를 주장하는 것인지 여부를 기준으로 판단된다.

2. 시간적 범위

- 처분사유의 추가·변경은 사실심 변론종결시 이전까지만 허용된다. 이는 법원의 심리 및 판결의 기초가 되는 사실 인정이 사실심 변론종결시를 기준으로 하기 때문이다. 다만, 추가·변경되는 사유 자체는 처분시를 기준으로 이미 존재하고 있었던 것이어야 하며, 처분 후 새롭게 발생한 사정 변화를 추가 사유로 삼아 처분의 적법성을 주장하는 것은 위법성 판단의 기준시 원칙에 위배되어 허용되지 않는다.

IV. 처분사유의 추가·변경의 인정 여부의 유형별 검토

1. 기본적 사실관계의 동일성을 인정한 사례

- 판례가 기본적 사실관계의 동일성을 인정한 사례는 주로 하나의 비위 행위나 사건에 대하여 당초 적용한 법률 조항이나 법률적 평가만 달리하는 경우이다. 예를 들어 음주운전 행위에 대해 당초 면허취소 처분의 근거를 특정 법규 위반에서 소송 중 동일 행위에 대한 다른 법규 위반으로 변경하는 경우 등이다. 또한, 공무원의 징계 사유 중 복종의무 위반을 소송 중 성실의무 위반으로 변경하는 것도 동일한 행위 자체에 대한 법률적 평가 변경에 불과하여 동일성을 인정하였다. 이는 원고가 이미 자신의 행위 자체에 대해서는 충분히 방어 준비를 할 수 있다고 보기 때문이다.

2. 기본적 사실관계의 동일성을 부정한 사례

- 판례가 기본적 사실관계의 동일성을 부정한 사례는 당초 처분 사유가 된 사실 외에 전혀 별개의 새로운 사실 또는 다른 시점에 발생한 사실을 추가하여 주장하는 경우이다. 예를 들어 당초 면허취소 처분의 사유가 특정 날짜의 교통사고였는데, 소송 중 전혀 다른 날짜의 음주운전 사실 등을 추가하여 주장하는 경우에는 동일성이 부정된다. 또한, 당초 처분 사유인 허가 조건 미이행과 추가 사유인 허위 문서 제출은 서로 독립된 행위로 간주되어 동일성이 부정된다. 이러한 경우 원고에게는 추가된 사유에 대해 방어할 예측 가능성이 전혀 없었기 때문에 방어권이 실질적으로 침해된다고 판단한다.

V. 처분사유의 추가·변경의 효과

- 처분사유의 추가·변경이 법원에 의해 허용되면, 추가 또는 변경된 사유는 당초 처분사유와 함께 법원의 심리 대상이 된다. 법원은 이러한 모든 사유를 종합하여 처분의 적법 여부를 판단한다. 만약, 당초 처분사유는 위법성이 인정되더라도, 추가된 사유가 적법하여 결과적으로 처분이 정당화된다면 원고의 청구는 기각된다. 반대로, 추가·변경이 허용되지 않은 경우 법원은 행정청이 추가·변경한 사유를 전혀 고려하지 않고 당초 처분사유만을 심리하여 위법성 여부를 판단하게 된다.

VI. 결론

- 처분사유의 추가·변경 제도는 행정처분의 실체적 적법성 유지 필요성과 국민의 방어권 보장 사이의 조화를 추구하는 중요한 심리 쟁점이다. 판례는 이를 기본적 사실관계의 동일성이 인정되는 범위 내에서만 제한적으로 허용함으로써, 행정청의 방어 기회 보장과 국민의 권리 보호를 균형있게 도모하고 있다.